刑法11——不法與罪責之外的可罰性要件 & 未遂犯

一、不法與罪責之外的可罰性要件（第六章）

- 位於三階論（該當→違法→有責）之後的「第四階段」
- 在罪責審查結束後才討論的要件

（一）客觀處罰條件

1. 概念

- **無關不法**（與法益侵害無關）
- **無關罪責**（與期待可能性無關）
- 國家純粹基於**刑事政策考量**所設置的可罰性條件

2. 最大特色

- **故意不用對它有認知**
- 只要客觀上該條件存在，即認為條件成就
- 也是**罪疑惟輕的例外**（不適用有利被告的推定）

3. 功能：限縮刑罰事由

錯誤理解	正確理解
把難以證明行為人認知的東西都歸為客觀處罰條件 → 擴張刑罰權	多加一個要件 → 讓犯罪成立多一道篩選門檻 → **限縮刑罰**

- 不能將客觀處罰條件當作擴張刑罰的工具，否則違反刑法§12「行為非出於故意或過失不罰」

4. 判斷公式

> 把疑似是客觀處罰條件的部分**遮住**，看法益侵害是否仍然存在：
>
> - 遮住後法益侵害**不存在** → 百分之百是**構成要件要素**
> - 遮住後法益侵害**仍存在** → 有可能是**客觀處罰條件**

5. 案例分析

條文	項目	遮住後	是否為客觀處罰條件
§238 詐術締婚罪	「因而致婚姻無效或撤銷裁判確定」	光以詐術締結無效婚姻 → 已侵害婚姻秩序	☑ 是（無爭議）
§227 與未滿14歲人性交	被害人年齡	單純與人性交 → 無法益侵害	❌ 不是（年齡是構成要件要素）
§283 聚眾鬥毆致死傷	致人於死或重傷	多數說認為是客觀處罰條件（分則再詳述）	☑ 多數說
§185-3 酒駕罪	酒測值數字	喝酒本身不是客觀處罰條件，**酒測值數字**才是	☑ 酒測值是
§130 廢弛職務釀成災害	釀成災害	有爭議（柯耀成老師過去主張，現已少人支持）	爭議
§185-4 肇事逃逸（2021修法後）	致人死傷	法定刑範圍由死傷狀況決定 → 與不法高度相關	❌ 修法後不可採

- **酒駕罪補充**：行為人不需知道具體酒測值，但必須意識到自己有喝酒且不適合開車
    - 被害人飲料被人摻入酒精而不自知 → 不成立§185-3（連喝酒都不知道）

（二）個人阻卻刑罰事由 & 解除刑罰事由

1. 個人阻卻刑罰事由（行為時即存在）

- **§288第三項**（墮胎罪）：因疾病或防止生命危險必要而犯罪 → 免除其刑
    - 現無適用空間：孕婦為避免生命危險而人工流產，可依優生保健法阻卻違法
    - 個人看法：比較像緊急避難的除外規定

- **§275第四項**（加工自殺罪）：約為同死而犯前三項之罪 → **得**免除其刑
    - 理由：相約自殺活下來的人也是想死的人，對其論罪科刑反而不利生命保護
    - **自殺不是犯罪的理由**：
        - 本質論：自己是生命的主人，處分自己生命未傷害他人
        - 技術面：既遂→被告死亡無法罰；未遂→罰反而不利生命保護

2. 解除（減免）刑罰事由（犯罪後才發生）

- 代表：**中止未遂**
- 臺灣用語問題：德國中止未遂是無罪（所以叫「解除」），我國中止未遂仍有罪 → 蔡聖偉老師認為應叫**「減免刑罰事由」**

二、未遂犯

（一）犯罪的行為階段

決意 → 陰謀 → 預備 → 著手 → 完成 → 既遂 → 終了

階段	意義	說明
決意	腦中浮現犯罪想法	刑法不罰思想，決意不可能成立犯罪
陰謀	兩人以上共同謀議	僅內亂外患等國家存在犯罪有罰
預備	犯罪準備階段	少數犯罪才處罰
著手	開始做構成要件行為	著手 = 未遂的起點
完成	行為做完	行為層面結束
既遂	構成要件完全實現	犯罪成立
終了	法益侵害結束	非所有犯罪都有（狀態犯既遂即終了）

- **完成 ≠ 終了**：完成是行為結束，終了是法益侵害結束
- **既遂後至終了前**的區間僅存在於**繼續犯**、**財產犯罪**等少數犯罪

思想犯的條文注意

- **§348-1 準擄人勒贖罪**：「擄人後意圖勒贖者」→ 條文字面無行為要件，須加上勒贖行為才不淪為思想犯
- **§335 侵佔罪**：傳統說「易持有為所有」= 主觀想法改變瞬間 → 亦須有外在行為

（二）預備犯

1. 形式預備犯（條文直接寫「預備」）

> **口訣：內外放火殺強人 + 一架飛機**（蔡聖偉老師原創圖，飛機為老師自加）

口訣	犯罪	條文
內	內亂罪	§100 等
外	外患罪	§103 等
放火	放火罪	§173
殺	殺人罪	§271③
強	強盜罪	§328③⑤
人	擄人勒贖罪	§347
飛機	劫持民用航空器罪	§185-1

2. 實質預備犯（本質為預備但條文未寫「預備」）

- **§199**：意圖偽造貨幣而收集器械原料 → 實質上是§195的預備
- **§187**：意圖供犯罪之用而持有軍用槍砲子彈
    - 「軍用」= 性能上可供軍事使用（手槍即算）
    - 考試有拿槍的題目，不要忘記§187

3. 形式預備犯的正當性爭議

- 批評：「準備行為」範圍太廣（買刀、比價、調查行蹤……都算準備），不符法律明確性
- 回應：預備行為須限於**重要的準備行為**才算

（三）未遂犯的處罰根據

學說	核心主張	支持者
客觀未遂論	未遂行為有法益侵害的**危險**	留日老師居多
主觀未遂論	未遂犯與既遂犯一樣壞（法敵對意思）	歷史說法，幾乎無人採
主客觀混合理論（印象理論）（德國通說）	行為人透過行為展現法敵對意思 → 一般人產生**法律秩序被動搖的印象**	留德老師居多

- 印象理論本質上是主觀理論，但加上客觀行為的展現作為限制

（四）未遂犯的四大要件

1. **故意**
2. **著手**
3. **不遂**（客觀構成要件未完全實現）
4. **法律明文**（須有處罰未遂的規定）

- **§277 普通傷害罪沒有罰未遂**，考試不要寫「傷害未遂」
- 「不遂」不只是結果未發生，客觀構成要件六要素（主體、客體、行為、結果、因果關係、情狀）任一未實現都是未遂

（五）著手的認定

1. 四種學說

學說	主張	評價
形式客觀說	開始做嚴格意義的構成要件行為	歷史說法，標準太嚴格
實質客觀說（行為危險說）	行為對法益產生**迫切危險**	留日老師多採
主觀說	行為人覺得開始做的時點	歷史說法，技術上難判斷
主客觀混合說（通說）	判斷對象：行為人犯罪計畫（主觀）；判斷標準：一般人標準有無迫切危險（客觀）	目前通說

- **實質客觀說 vs 主客觀混合說的核心差別**：判斷對象不同
    - 客觀說 → 純客觀事實
    - 混合說 → 行為人腦中的犯罪計畫
- 差別最大之處：**不能未遂案例**（如花蓮開槍案）

2. 著手認定的各種案例

（1）已做構成要件行為 →原則上著手

- 實務案例：男生套上保險套，距女生陰道約三公分 → 已著手（104年判決）

（2）隔離犯的著手（行為完成到犯罪實現間有時間/空間/需被害人配合的間隔）

學說	主張	嚴格程度
嚴格個別理論（實務）	做完行為即著手	最寬鬆
修正個別理論	損害流程失控、行為人想挽回也來不及時	中間
整體理論（許恆達老師）	被害人端也進入損害攻擊範圍時	最嚴格

- 隔離犯著手理論 = 間接正犯的著手理論

（3）尚未進行構成要件行為

- 進入客廳物色財物 → 主客觀混合說：著手；實質客觀說：不一定

（4）結果提前發生案例

- 行為人計畫用安眠藥迷昏再持刀殺，誤拿毒藥致中毒
    - 實質客觀說 → 著手（客觀上就是毒藥）
    - 主客觀混合說 → 未著手（犯罪計畫中用安眠藥→離殺人還遠）

（5）加重構成要件的著手

- **一律回歸基本構成要件認定**，不以加重事由判斷著手
- 範例：加重竊盜（§321）侵入住宅 → 著手是因為已開始搜尋財物（§320的基本構成要件），非因§321
- §222第四款以藥劑犯姦 → 下藥即著手，因為下藥本質是§221的強暴行為

（六）普通未遂的法律效果

- §25：**得減輕其刑**（可減可不減，通常會減）
- 傳統稱「障礙未遂」（日語用語），現多稱「普通未遂」

（七）不能未遂（§26）

1. 條文與要件

> §26：行為**不能發生犯罪之結果**，又**無危險**者，**不罰**。

要件	說明
不能發生犯罪結果	篩選意義不大，幾乎所有未遂都套得出來
無危險	判斷關鍵

- 2006年修法後改為不罰（之前有罪）
- 不能未遂在預備階段 → 舉重明輕，當然也不罰

2. 不能發生犯罪結果的三種類型

類型	說明	例子
主體不能	因誤認**事實**而以為自己是主體	業務經理不知被開除，仍出去簽約背信
客體不能	行為客體不存在	對已死之人開槍、被害人不在家時掃射
手段不能	手段無法遂行犯罪	槍枝射程不夠、毒藥劑量不足

- **主體不能的正確理解**：指事實誤認（不知已被開除），非法律評價的誤認（保全不知自己非公務員 → 非主體不能）

3. 無危險的判斷（三說）

學說	判斷視角	標準	評價
客觀危險說	事後判斷	自始不能=無危險（絕對不能）；偶然因素=有危險（相對不能）	歷史說法，貫徹則所有未遂都變不能未遂
具體危險說（新客觀說）	事前一般理性第三人	該領域旁觀者是否會覺得有危險	通說／多數說
重大無知說	日常生活知識	行為人出於日常生活知識的重大無知 → 無危險	留日老師多採

客觀危險說的批評

- 事後（上帝視角）來看，將來發生什麼都已知道 → 幾乎所有未遂都「無危險」
- 比喻：恐怖片看第二遍不會恐怖

具體危險說的特色

- 危險不是事實，是**價值判斷**、是**感受**
- 旁觀者在專業領域須為具有專門知識的人
    - 製毒案 → 懂製毒的旁觀者判斷
    - 但販毒 → 不需要專業旁觀者（販毒不需專業）

重大無知說的案例

重大無知（不罰）	非重大無知（有罰）
用彈弓射民航機	誤算槍枝射程
給孕婦喝菊花茶使其流產	算錯毒品提煉方式
給糖尿病患喝全糖飲料致死	算錯毒藥劑量
以為田徑裁判起跑槍是真槍	誤拿腸胃藥當毒藥

三說比較案例

案例	客觀危險說	具體危險說	重大無知說
乙已被甲射殺，丙不知乙死再刺兩刀	無危險	有危險	有危險
搶警察配槍但沒裝子彈即開槍	無危險	有危險	有危險
把腸胃藥誤認為毒藥拿去毒人	無危險	**有危險**	**無危險**（非重大無知但…）
拿不存在面額的外幣去銀行兌換	無危險	無危險	無危險

- 具體危險說與重大無知說結論大多相同，差異案例：搞錯容器內裝物（非日常知識的重大無知，但旁觀者看不出）

4. 迷信犯

- 定義：透過自然科學無法驗證的方式實現犯罪（如扎稻草人）
- **不具規範上的意義**，只是現象描述
- 須先確認有無故意：
    - 半信半疑、單純願望 → 無故意
    - 真的確信 → 有故意 → 不能未遂（手段不能＋無危險）→ 不罰
- 考試不用特別提「迷信犯」概念

5. 不能未遂在三階論的定位

定位	說明	支持者
構成要件不該當（紅色線）	不能未遂無著手（客觀著手理論下）	留日老師
三階外的阻卻刑罰事由（黃色線）	該當違法有責，但基於刑事政策不罰（事理上的阻卻刑罰事由）	蔡聖偉老師（學理主流）

- 蔡聖偉老師的論理：
    - 罰未遂犯的目的 = 維護行為規範的效力
    - 不能未遂行為即使不罰，也不會有人想模仿 → 不會破壞行為規範效力 → 無處罰必要

6. 區別實益

主要實益：共犯（教唆犯 / 幫助犯）

- 共犯成立前提 = 正犯須**該當且違法**（共犯從屬性）

定位	正犯（不能未遂行為人）	共犯能否成立
構成要件不該當（紅色線）	連構成要件都不該當	❌ 不能成立共犯
三階外（黃色線）	該當＋違法＋有責，僅三階外不罰	☑ 可能成立共犯

- 範例：確信扎稻草人可殺人，跟神壇師父要稻草人 → 師父是否成立幫助犯？取決於定位

正當防衛

- **通說：不能對不能未遂正當防衛**
    - 構成要件不該當說 → 無不法，無從防衛
    - 三階外說 → 雖有不法，但不能未遂對法益無危險 → 不構成「侵害」
    - 連結前面：假性侵害的概念（P147）

本堂課重點回顧

1. **客觀處罰條件**：無關不法罪責、故意不用認知、限縮刑罰事由、遮住公式判斷
2. **犯罪行為階段**：決意→陰謀→預備→著手→完成→既遂→終了
3. **有罰預備的犯罪**：內外放火殺強人＋飛機
4. **未遂犯處罰根據**：印象理論（通說）
5. **著手認定**：主客觀混合說（通說）—以犯罪計畫為判斷對象，一般人標準判斷迫切危險
6. **隔離犯著手**：嚴格個別理論（實務）vs 整體理論（許恆達老師）
7. **加重構成要件著手**：一律回歸基本構成要件
8. **不能未遂§26**：不能發生結果＋無危險→不罰
9. **無危險判斷**：具體危險說（多數說）、重大無知說
10. **不能未遂定位**：三階外阻卻刑罰事由（學理主流），主要區別實益在共犯